

1500175-21.2022.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME FACCHINI BOCCHI AZEVEDO

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... de maconha, todavia, não pratica o tráfico de drogas. Admite quando ainda adolescente foi apreendido por ato infracional tráfico de drogas, entretanto, não mais comercializa drogas. Após ter sido colocado em liberdade da fundação casa, não mais se envolveu com o tráfico de drogas. Não consegue largar o vício da maconha e inclusive precisaria ser internado. Finaliza ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Jardim América, Tupã - SP - cep 17605-900

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500175-21.2022.8.26.0592 - Controle 2022/000820

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI MOREIRA JÚNIOR

Aos 18 de novembro de 2022, às 15:00h, na sala de audiência virtual da Vara Criminal do Foro de Tupã, Comarca de Tupã, Estado de São Paulo, realizada neste formato de modo excepcional, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, tudo conforme autorizado pelo E. Conselho Superior da Magistratura (Provimentos CSM nºs 2.554/2020 e 2.557/2020) e pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 314/2020), sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GUILHERME FACCHINI BOCCHI AZEVEDO, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais foi constatada e certificada a presença no sistema virtual do DD. Promotor(a) de Justiça LUCILA AKEMI NAKAGAWA, do(a) Dr(a). Defensor Público RICARDO DE PAULA MIOTO e do réu. Pelas partes inicialmente foi dito que não viam impedimento à realização do ato pelo sistema virtual. Foi oportunizado à Defesa o direito de contato reservado com o réu através do sistema virtual. A seguir foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum e, ao final, o réu foi interrogado sobre os termos da acusação, de acordo com o artigo 188, incisos I a VIII do CPP, mediante sistema de gravação de áudio e vídeo, na forma como autoriza o artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal. Fica consignado que a gravação desta audiência encontra-se disponível para consulta mediante acesso ao portal E-SAJ. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito que declarava encerrada a instrução e determinava a realização dos debates, tendo sido dada a palavra ao(à) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, que assim se manifestou: "MM. Juiz(a), DAVI MOREIRA JÚNIOR está sendo processado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput da Lei nº. 11.343/06 uma vez que no dia 20 de maio de 2022, às 18h30, na Avenida Idenolphi Semeghini, com o cruzamento da Rua Pioneiro Aldery Pires, Conjunto habitacional Papa João Paulo II, nesta cidade e Comarca de Tupã, transporta e trazia consigo, com a finalidade de entregar a consumo de terceiros, 16 invólucros plásticos, contendo em seu interior cocaína, em forma de crack, com peso líquido de 1,2 gramas (peso bruto 9,00g) e 05 "micro tubos

plásticos, tipo "(ependorfs), contendo cocaína, com peso líquido de 1,20 gramas (peso bruto 8,70g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 10 e laudo de constatação de fls. 15/17). As referidas substâncias causam dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/9. O pedido condenatório formulado na denúncia deve ser julgado procedente. O crime está comprovado pela somatória do auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de exibição e apreensão a fls. 10, laudo de constatação das drogas a fls. 15/17, imagens de fls. 19/20, laudo definitivo de fls. 128/131, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo. A autoria também é certa e recai de forma tranquila na pessoa do acusado. É o que demonstra o conjunto probatório que agora passo a explorar. Vejamos.

Interrogado em Juízo, o réu Davi Moreira Júnior negou a prática dos fatos que lhe são imputados. Os policiais militares Renato Fernandes Fantes e Alex dos Reis Pacheco, em síntese, declararam que receberam denúncia da prática de tráfico de drogas no local, noticiando especificamente sobre DAVI, inclusive noticiando suas vestimentas e que o réu deixava as drogas ao pé de uma árvore e procedia a venda. Relatou que no local indicado quando avistaram o réu que dispensou algo ao solo, motivando a abordagem. Assim, constataram que o objeto dispensado pelo réu se tratava de duas porções de crack e, em buscas pelo local, ao pé da citada árvore, dentro de uma meia, lograram encontrar mais 14 porções de crack, idênticas às dispensadas pelo réu e mais 05 pinos de cocaína. Em poder do réu, localizaram R\$ 160,00. Relatou que acusado ao ser encontrada as drogas tentou se evadir do local e proferindo ameaças e tentando colocar a população contra a atuação policial. A evasiva apresentada pelo acusado deve ser de pronto afastada, uma vez que contrariada pelo conjunto probatório dos autos, que o incrimina frontalmente, evidenciando que estava praticando o tráfico de drogas. As versões dos agentes de segurança foram firmes e convincentes a consignar que o acusado, ao avistar os policiais, dispensou duas porções de crack ao chão, motivando a localização de outros entorpecentes embalados de forma idêntica aos dispensados pelo réu, os quais se destinavam ao ilícito comércio. De se consignar, portanto, que os depoimentos dos policiais são fidedignos, encontrando plena harmonia com as declarações prestadas durante a investigação. Frisa-se que eles descreveram com detalhes a dinâmica dos fatos, depoimentos esses que estão inseridas em um contexto probatório seguro, harmonioso e estreme de dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva, constituindo elemento relevante para embasamento do decreto condenatório. Como se percebe, os depoimentos dos policiais militares que confirmaram os elementos de provas colhidos na fase inquisitiva, que sustentou a descrição dos fatos descritos na inicial, que demonstraram a autoria por parte do acusado. Ademais, não há qualquer razão para que não se dê crédito ao depoimento das referidas testemunhas, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de maculá-las, nem mesmo que haviam motivos para querer prejudicar o acusado, imputando, falsa e levianamente, a autoria dos fatos a ele, em nada lhes aproveitando condenação de quem sabidamente inocente. Cabendo, ainda, a ressalva de que estão sujeitos às penas do artigo 339 do Código Penal. Outrossim, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como as demais circunstâncias da prisão do réu indicam que a droga com ele localizada era destinada à traficância. A condenação, portanto, é de rigor. Cumpre agora manifestar-me quanto à dosimetria da pena. As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, de modo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Na segunda fase e terceira fase, nada há a considerar. Inviável a aplicação da benesse do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, pois o réu não demonstrou que exerce atividade lícita, fazendo do tráfico, portanto, seu único meio de vida. O regime de cumprimento inicial da pena deverá ser o semiaberto nos termos do artigo 33, do Código Penal. Isso porque, diante da quantidade de pena aplicada e da gravidade concreta dos delitos praticados, mostra-se como única solução ao caso em concreto. Por fim, anoto ser impossível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em relação ao delito de tráfico de drogas. E tal afirmação decorre não apenas do montante de pena que espero seja aplicada ao réu, mas também porque se trata de solução que não guarda coerência com a

determinação imposta no artigo 2º da Lei 8.072/90. Ante o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO requer seja julgada PROCEDENTE a presente ação penal, nos termos acima expostos.”. Dada a palavra a Defesa, assim se manifestou: “MM. Juiz(a), DAVI MOREIRA JÚNIOR foi denunciado pela infração, em tese, ao artigo 33, “caput”, da lei nº 11.343/06, pois supostamente, mantinha consigo para venda, substâncias de uso proscrito. Encerrada a instrução processual, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal. As testemunhas policiais Renato Fernandes Fantes, e Alex Dos Reis Pacheco, em seus depoimentos, afirmaram que estavam em patrulhamento, quando avistaram o acusado em ponto conhecido de venda de drogas. Ao se aproximarem, perceberam que o acusado dispensou algo no chão, motivo pelo qual o abordaram. Em busca pessoal, foi encontrado R\$ 160,00 em espécie, bem como, nas imediações, foram encontradas porções de crack, iguais às que teriam sido descartadas pelo acusado. O acusado, DAVI MOREIRA JÚNIOR, em seu interrogatório, negou a propriedade do entorpecente. Admitiu ser usuário de maconha. Confessou que já teve envolvimento com o tráfico quando mais novo, mas que, atualmente, não tem mais nenhuma relação com o tráfico. 1. DA ILICITUDE PROBATÓRIA Abordagem fundada apenas na atitude suspeita. Impossibilidade. Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos: É preciso reconhecer que, no caso em análise, a apreensão das drogas derivou de uma atuação ilícita dos policiais militares, tendo em vista que amparada na simples constatação de uma “atitude suspeita” de acusado andando em rua conhecida por ser local de tráfico de drogas, o que não configura o flagrante e, por isso, torna ilícitos por derivação os elementos de prova daí decorrentes (CF, art. 5º, LVI e CPP, art. 157, § 1º). Nesse ponto, rememore-se que o art. 5º, LXI, da Constituição Federal, prescreve que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. Em sentido aproximado, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7.3 prescreve que “Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários”. Já o art. 9.1 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos estipula que “Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Ninguém poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente. Ninguém poderá ser privado de liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei e em conformidade com os procedimentos nela estabelecidos”. Perceba-se, por conseguinte, que o ordenamento nacional protege o jurisdicionado contra detenções arbitrárias, estabelecendo que alguém somente poderá ser preso em conformidade às hipóteses previstas em lei. Nesse sentido, em se tratando de prisão em flagrante, o

Código de Processo Penal, art. 302, assim define a situação de flagrância: “Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”. Se é assim, a prisão em flagrante somente se legitima quando constatada alguma das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal. Nesse trilho, em se tratando de norma que interfere na liberdade individual, impõe-se a sua interpretação taxativa. Por isso, não se pode admitir uma detenção que não se pautar em critérios legalmente estipulados, amparando-se em uma suposta “atitude suspeita” ou em suposto “nervosismo” demonstrado pelo cidadão. Do contrário, estar-se-á diante de uma detenção ilegal, arbitrária. Nesse sentido, já decidiu a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Caso Fernández Prieto e Tumbiero vs. Argentina, sentença de 1/9/2020, tradução livre, §§ 81 e 82). Por via de consequência, no caso ora analisado, não há que se falar em flagrante porquanto não houve qualquer motivação legítima para proceder à abordagem. Nesse diapasão, os policiais não presenciaram a prática do crime e não presenciaram o acusado em situação de flagrante presumido/impróprio (CPP, art. 302, III e IV), visto que efetuaram a abordagem por conta de conhecer o acusado em meio policial e uma singela “atitude suspeita”, uma vez que, diante de seus próprios relatos, o denunciado estava na rua, quando, durante o patrulhamento, decidiram realizar a abordagem pessoal, com base em suposta dispensa de material ilícito. Assim, a apreensão das drogas, no caso sub examine, é elemento de prova

ilícito, tendo em vista a indevida abordagem. Por esse motivo, o auto de apreensão das drogas deverá ser desentranhado dos autos, visto que é inadmissível o seu ingresso no processo (CF, art. 5º, LVI c. c/ CPP, art. 157) e, como consequência, o laudo de constatação e o laudo definitivo deverão ser reconhecidos como provas ilícitas por derivação, não podendo servir para formação da convicção judicial. Vale dizer: tais elementos mostram-se incapazes para atestar a materialidade do delito imputado ao acusado. Se é assim, impõe-se, na forma do art. 386, V, do Código de Processo Penal, a reforma da r. sentença e a consequente absolvição do apelante.

2. DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA: Com efeito, da acurada análise do conjunto fático-probatório, produzido em Juízo, único capaz de sustentar um decreto penal condenatório, verifica-se que a autoria delitiva não restou adequadamente comprovada pelos elementos coligidos na fase judicial. Como se pode observar, na fase judicial, muito pouco se produziu a respeito da dinâmica dos fatos, restando apenas a reprodução dos relatos obtidos em solo policial, os quais, isoladamente, não são suficientes para sustentar um decreto condenatório. A única circunstância que sustenta o presente procedimento é a diminuta quantidade de droga encontrada próxima ao acusado. Ora não há como comprovar que a droga encontrada no local era, de fato, do acusado, pois, conforme afirmado pelos policiais, a região é ponto de tráfico de entorpecentes, o que não se descarta a possibilidade de os entorpecentes serem de propriedade de outras pessoas que ali realizam o tráfico. Ademais, os relatos oferecidos pelos Policiais, contrariamente ao que ocorre com os demais cidadãos, não são dotados da necessária imparcialidade, na medida em que os agentes da lei tenderão, por certo, a corroborar as diligências (e a própria prisão) efetivadas na fase extraprocessual, sendo naturalmente inclinados, portanto, a atestar a lisura das suas ações realizadas na fase investigativa. Isso posto, percebe-se que o conjunto probatório é frágil, não se podendo constatar, além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do apelante. Há, no mínimo, dúvida acerca da imputação. Dessa forma, o interrogatório do acusado se coaduna com a prova oral produzida em juízo. Analisando o conjunto probatório, é forçoso reconhecer a absoluta falta de provas para a condenação, sendo de rigor a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Sendo assim, diante da fragilidade probatória, pleiteia-se a ABSOLVIÇÃO, nos termos do art. 386, VII, do CPP. No mais, por força do princípio da presunção da inocência – insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal vigente e no art. 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – deve o órgão acusatório provar a existência de todos os elementos do fato imputado na denúncia para que possa haver condenação penal, não sendo esta, todavia, a hipótese dos autos. Com efeito, faz mister a presença de um conjunto probatório harmonioso e robusto para a imposição de um édito condenatório, o que, todavia, não ocorre na hipótese dos autos. De rigor, portanto, a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

3. DA DECLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS: Em atendimento aos princípios da eventualidade e da ampla defesa, requer-se a desclassificação de referida imputação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, uma vez que inexistem quaisquer provas seguras, com a precisão exigida pelo Direito Penal, de que a droga apreendida não fosse para uso próprio. Ainda nesse sentido, frise-se que o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, dispõe que “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente” (grifamos). Percebe-se, assim, que um dos elementos decisivos para a diferenciação entre o mero usuário e traficante, é a quantidade de drogas encontradas em poder do imputado. Nessa linha de raciocínio, em recente decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos Autos da Revisão Criminal n. 0025831-60.2017.8.26.0000, valendo-se de pesquisas científicas efetuadas para diferenciar o traficante do usuário, rescindiu condenação proferida pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, entendendo que os fatos estariam mais bem enquadrados no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. É justamente o caso narrado nestes autos, em que a quantidade de drogas apreendida em poder do acusado é pequena, corroborando suas declarações no sentido de que é usuário. Nesse

sentido, é certo que a imputação do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 seria demonstrada apenas com base nos depoimentos dos policiais militares, elementos de prova de fraco teor de convicção. Assim, não demonstrado o intuito de comercialização da droga, impõe-se a desclassificação, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0001018-89.2017.8.26.0542, Rel. Diniz Fernando, julgado em 16/3/2020. Com isso, resta configurada a conduta de uso de drogas, mostrando-se imperiosa a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas. E, uma vez efetuada a desclassificação, exsurtem algumas consequências. 4. DA DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL: Em caso de condenação, impõe-se a aplicação da pena base seja fixada no mínimo na primeira fase de dosimetria, considerando-se as circunstâncias favoráveis do art. 59 do Código Penal, bem como a primariedade do acusado. Diga-se, ainda, que muito embora o artigo 42 da Lei de Drogas estabeleça como critério para a dosagem da pena a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, é evidente que havia apenas um tipo de droga no local, não configurando a possibilidade de tal aumento. Além disso, a quantidade de drogas encontrada apreendida é ínfima e certamente não serve para configurar o aumento pleiteado pela acusação, pelo que requer sua fixação no mínimo legal. Fixação do regime inicial menos gravoso (aberto) para o início do cumprimento da sanção privativa de liberdade, considerando a ausência de circunstâncias pessoais e objetivas desfavoráveis (Súmulas 440 e 269/STJ; 718 e 719/STF) tendo também em vista que o acusado é primário, pois, na data dos fatos, não ostentava nenhuma condenação com trânsito em julgado contra si. No caso em exame, deveria ter sido aplicado o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006. De fato, é fácil concluir que o imputado preencheu todos os requisitos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei de Drogas: (a) ele é primário, (b) possui bons antecedentes, (c) não há prova de íntegra organização criminosa ou (d) que se dedique a atividades criminosas. Desta forma requer a aplicação do artigo 33, §4º da lei 11.343/2006. 5) SUBSTITUIÇÃO POR PRD Uma vez que se torna imperiosa a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, mostrar-se-á cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. Concessão de recorrer em liberdade (CADH, art. 8.1 e CPP, art. 312): Considerando ainda que se findou a fase de instrução probatória do presente processo e não mais presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar (CF, art. 5, LVII, c/c CPP, art. 312), requer-se a concessão da liberdade provisória ao acusado, reconhecendo-se o direito de recorrer em liberdade (STJ, HC 96.980/PA).". Pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: "DAVI MOREIRA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, 20 de maio de 2022, às 18h30, na Avenida Idenolphi Semeghini, com o cruzamento da Rua Pioneiro Aldery Pires, Conjunto habitacional Papa João Paulo II, nesta cidade e Comarca de Tupã, transporta e trazia consigo, com a finalidade de entregar a consumo de terceiros, 16 invólucros plásticos, contendo em seu interior cocaína, em forma de crack, com peso líquido de 1,2 gramas (peso bruto 9,00g) e 05 "microtubos plásticos, tipo (eppendorfs), contendo cocaína, com peso líquido de 1,20 gramas (peso bruto 8,70g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a denúncia que "(...) policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em região conhecida como ponto de venda de drogas quando avistaram um grupo de pessoas, sendo que DAVI, ao perceber a presença policial, deixou o grupo caminhado às pressas e dispensando algo ao solo. Diante da conduta suspeita do denunciado os militares o abordaram e, ao verificar o que ele havia dispensado ao solo, encontraram duas porções de crack. Em revista pessoal os policiais encontraram a quantia de R\$ 160,00 com DAVI. Os policiais realizaram buscas pelo local mais 14 porções de crack, semelhantes àquelas encontradas com o denunciado e mais 05 microtubos plásticos, tipo eppendorfs contendo cocaína que estavam no solo". Por r. decisão liminar em Habeas Corpus n. 2112730-51.2022.8.26.0000 foi revogada a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares (fls. 68/80 e 81), confirmada por decisão de fls. 112/122. Oferecida a Denúncia, o réu foi regularmente notificado (fls. 145) e apresentou defesa prévia (fls. 148/149). Noticiado o descumprimento das medidas cautelares impostas, foi decretada a prisão preventiva do acusado às

fls. 257/258. A denúncia foi recebida aos 16 de setembro de 2022 (fls. 279/281), sendo o réu citado às fls. 304. Em audiência de instrução, debates e julgamento, foi colhido o depoimento das testemunhas arroladas e, ao final, interrogado o réu. Em alegações finais, a representante do Ministério Público opinou pela procedência da ação pugnando pela condenação do réu nos termos da Denúncia. Já a defesa entende não demonstradas a materialidade e autoria delitivas, postulando a absolvição do réu. É o relatório. Decido. A pretensão acusatória é procedente. A materialidade dos crimes imputados aos acusados foi evidenciada pelas provas colhidas, em especial pelos depoimentos das testemunhas, boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 10), laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 15/17), pelo laudo pericial definitivo (fls. 128/131) e pelos demais elementos de convicção coligidos aos autos. A autoria é certa. Isso porque diante das próprias circunstâncias da abordagem policial, a respeito das quais as testemunhas de acusação, policiais militares que participaram da abordagem, narraram toda dinâmica, denotando coerência e harmonia em seus depoimentos, bastantes elucidativos ao deslinde do feito. Em solo policial, a testemunha RENATO FERNANDES FANTES, policial militar, relatou que "o depoente comanda equipe de Força Tática. No início desta noite, realizavam patrulhamento nos Bairros Jamil Dualibi e Papa João Paulo II, localidade com alto índice de crimes, principalmente aqueles envolvendo o tráfico de drogas. Ao ser aproximar da Rua Idenolphi Semeghuine com a Rua Pioneiro Valdery Pires, avistaram um grupo de rapazes, sendo que perceberam que o ora conduzido saiu caminhando às pressas e dispensou algo ao solo. Ao ser abordado, o identificaram como sendo a pessoa de alcunha Barney, conhecido dos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas. Constataram que havia dispensado duas porções de crack, as quais foram recuperadas. Passaram a procurar pelas imediações mais drogas, uma vez que tinha notícias de que aquele ponto era de venda de drogas por intermédio de Barney. Acabaram por encontrara escondido no solo, mais quatorze porções de crack, embaladas de forma semelhante aquelas que foram dispensadas pelo mesmo e ainda mais cinco eppendorff's contendo cocaína. Ainda em poder de Barney foi encontrada a quantia de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) em nome de diversos valores. AO perceber que as porções de drogas foram encontradas, Barney tentou empreender fuga e passou a gritar contra os policiais, inclusive dizendo que iria matá-los. Foi contido e algemado ante receio de fuga e a própria particularidade do bairro, sendo dada voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Esclarece que o ora conduzido foi identificado como Davi Moreira Júnior. Finaliza informando que o ora conduzido teve todos seus direitos preservados" (fls. 02, sic). Em juízo, a testemunha Renato, reiterou a versão e então passou a ameaçar a guarnição e tentou jogar a população contra os policiais. Em solo policial, a testemunha ALEX DOS REIS PACHECO, policial militar, relatou que "integra equipe de Força Tática, comandada pelo Sgt. PM Fantes. No início desta noite, realizavam patrulhamento principalmente nos Conjunto Habitacionais Jamil Dualibi e Papa João Paulo II, bairros com alto índices de violência, principalmente aqueles relacionados ao tráfico de drogas. Quando se aproximavam de uma esquina conhecida como ponto de venda de drogas, perceberam que o ora conduzido apressou o passo e dispensou algo ao solo. Foi então abordado e assim identificado como sendo o indivíduo de alcunha Barney, conhecido dos meios policiais e envolvido com o tráfico de drogas. Constataram que o que havia sido dispensado eram duas porções de crack, embaladas de forma própria para a venda. Como tinham notícias que naquele local, Barney fazia a venda de drogas, passaram a procurar por mais drogas nas imediações e acabaram por encontrar escondidas no solo, mais quatorze porções de crack, embaladas na forma semelhante aquelas que foram dispensadas pelo mesmo, além de mais cinco eppendorff's contendo a droga conhecida como cocaína. Em revista pessoal em Barney, encontraram a quantia de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) em notas de diversos valores. Ao perceber que havia sido encontrada as demais porções, Barney tentou empreender fuga e passou a gritar com os policiais, dizendo que iriam matá-los. Foi dominado, algemado e dada voz de prisão pela prática do crime de tráfico de drogas. Esclarece que o uso de algemas foi necessário ante o receio de fuga e particularidade do bairro em que estavam. O ora conduzido foi identificado como Davi Moreira Júnior e teve todos

seus direitos preservados. Finaliza informando que quando ainda menor de idade, Davi Moreira Júnior foi apreendido por ato infracional tráfico de drogas" (fls. 03). Em juízo, explicou que a denúncia que receberam era específica mencionando a vestimenta e o local onde estava o réu, e então, após se deslocarem ao local, verificaram o réu no local e a droga; que dentro de uma meia havia porções de crack idênticas às dispensadas pelo réu. Em seu interrogatório policial, DAVI MOREIRA JÚNIOR negou os fatos imputados a ele. Disse que "a droga apresentada pelos policiais militares não lhe pertence. Confirma ser usuário de maconha, todavia, não pratica o tráfico de drogas. Admite quando ainda adolescente foi apreendido por ato infracional tráfico de drogas, entretanto, não mais comercializa drogas. Após ter sido colocado em liberdade da fundação casa, não mais se envolveu com o tráfico de drogas. Não consegue largar o vício da maconha e inclusive precisaria ser internado. Finaliza informando que está sendo preso injustamente" (fls. 04). Em juízo, declarou que foi abordado perto de outro rapaz, que os policiais soltaram; que decidiram ficar com o declarante; que estava morando na casa de sua tia; que estava levando leite e dinheiro para sua mulher; que passou perto deste terceiro rapaz, e então foi enquadrado junto com o dito terceiro; que liberaram o terceiro e prenderam o declarante; que ainda estava com a roupa do serviço. Pois bem. A despeito da negativa do réu, a prova oral produzida demonstrou satisfatoriamente a autoria delitiva dos fatos imputados na Denúncia, e sem sombra de dúvidas recai sobre a pessoa do réu. A testemunhas confirmaram que a droga apreendida pertencia ao réu, conhecido nos meios policiais desde a menoridade como traficante de drogas, tanto que já foi apreendido por ato infracional. Ademais, os policiais que realizaram a abordagem que culminou na prisão em flagrante delito, contaram de forma uníssona e com riquezas de detalhes as circunstâncias fáticas em que se deram a apreensão da droga, as quais de forma segura se vinculam com réu. Por sua vez, deve-se tomar com reservas a versão aventada pelo réu, posto que imprecisa e divergente do que apurado no processo, restando isolada frente às informações prestadas pelas testemunhas de acusação. Ademais, o fato de ser usuário não exclui a possibilidade da prática do crime de tráfico pelo acusado. Na ocasião, os agentes viram que o objeto dispensado pelo réu se tratava de drogas, idênticas às encontradas escondidas no solo durante as buscas pelas imediações. Ora, além do comportamento do acusado ao perceber a presença da guarnição, tem-se que os milicianos informaram que o réu é conhecido - conforme informação recebida de populares - como praticante do comércio espúrio de entorpecentes naquele local. De todo modo, não há nulidade alguma no flagrante pois o réu foi surpreendido dispensando drogas, com mais drogas no local onde estava, havendo pois justificativa para a abordagem e prisão em flagrante. Além disso, não se pode desconsiderar que, no contexto da abordagem policial, foi encontrada quantia monetária em notas de diversos valores, e as drogas que o réu transportava estavam embaladas da mesma maneira que as porções escondidas no solo. As circunstâncias da prisão, pois, revela que o acusado estava

exercendo o tráfico ilícito de drogas. Quanto ao valor da prova testemunhal policial, anote-se que vige no processo penal brasileiro o princípio da livre convicção motivada (ou da persuasão racional), cabendo ao julgador valorar o conjunto probatório, externando sua conclusão dentro de raciocínio lógico-jurídico. Dos agentes públicos em questão emana a fé pública, e não há indício algum nos autos que torne imprestável a prova, ou viciados os seus depoimentos. Não resta dúvida acerca da materialidade e autoria do delito, bem como da destinação das drogas ao comércio. O entorpecente estava acondicionado em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão. E não se tem notícia nenhuma de que o réu estivesse, no momento do flagrante, trabalhando. Esclareço que a jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa de menor credibilidade da testemunha a sua condição de policial, até mesmo porque "se a defesa não contraditou os policiais, não pode pretender, no recurso, invigorar seu depoimento. Tivera razões para demonstrar a insubsistência do depoimento e deveria tê-las invocado logo após a qualificação da testemunha. A aceitação de seu relato permite se presuma a inexistência de qualquer suspeita quanto à sua parcialidade" (TACRIM; Juiz José Renato Nalini; Julgados do TACRIM; Fiúza Editora; Vol. 39:97). A

forma de acondicionamento da droga, em condições para posterior fracionamento, aliada a todo o sólido teor probatório colhido durante a instrução processual, tornam certa a autoria do crime imputada ao réu. Vale destacar que o peso da droga encontrada não se enquadra nos critérios para ensejar a destinação para consumo pessoal, já que se traduz em valor pecuniário considerável. Neste sentido, confirmam-se as balizas fixadas pelos precedentes das Cortes Superiores: "Anotar-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas o que evidencia que a droga apreendida era destinada a entrega a consumo de terceiros. Dessa forma, a quantidade de gramas era suficiente para o comércio e lesar a saúde pública." (TJSP, Ap. nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 26/10/2017). Assim, em cotejo com tais parâmetros quantitativos fornecidos no caso, notadamente a forma como embalada a droga, a dinâmica dos fatos por ocasião da ocorrência, havendo notícia de que o réu se dedicava ao comércio espúrio, tem-se que a quantidade de droga apreendida em depósito para o réu afasta a tese de consumo pessoal. Logo, as condutas consistentes em "transportar e trazia consigo, com a finalidade de entregar a consumo de terceiros", bem como guardava, restaram efetivamente comprovadas, ao passo que a prova que se exigia em contrapartida, decorrente dos fatos desconstitutivos afirmados pelo acusado, não foi produzida de forma convincente. Encontra-se, pois, o acusado DAVI MOREIRA JUNIOR incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Fixadas tais balizas, passo, então, à dosimetria da pena: Na primeira fase, atento às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena no mínimo legal ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas, mantendo-a, portanto, em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa. Em atenção ao Tema 712 do STF, a quantidade de droga será utilizada/considerada na última fase dosimétrica ("As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena." - ARE 666.334 RG/AM). Ausentes agravantes. De outro vértice, há a circunstância atenuante genérica da menoridade (CP, art. 65, inciso I). Entretanto, como não se admite a diminuição da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), mantenho a pena intermediária no patamar mínimo. Na última fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Porém, em razão da quantidade de porções de drogas apreendidas e de seus tipos diversos e especialmente viciantes, a redução deve se dar pela metade, ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa, fixados no mínimo legal. Não havendo outras circunstâncias modificativas, torno as penas até aqui fixadas em definitivas. Fixo o valor do dia-multa no piso porquanto ausentes evidências quanto à real condição econômica do réu nos autos. O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, pois os tipos de droga apreendidos com o réu são de alto potencial viciantes (crack e cocaína), bem como conta o réu com passagem por ato infracional (com internação). No mais, tentou empreender fuga e passou a gritar contra os policiais, inclusive dizendo que iria matá-los, tudo a recomendar o regime intermediário, que é necessário e adequado em caso de descumprimento das penas restritivas de direitos fixadas à frente. Frise-se, neste ponto, que em sessão ocorrida no dia 8/9/2021, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa(m) ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A mesma premissa serve, por consequência, para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, aliado ao art. 42 da LD. Neste sentido: "(...) A Corte de origem justificou a fixação do regime inicial mais gravoso com base nas peculiaridades do caso concreto - notadamente na quantidade e natureza das drogas apreendidas e nos registros infracionais anteriores - elementos que, de fato, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o

cabível em razão da reprimenda aplicada. 6. Agravo regimental não provido" (AgRg no HC n. 698.311/SP, Min. Rel. Rogerio Schietti Cruz Mas não é só. , Sexta Turma, j. 19/5/2022). Recomendável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos: a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade substituída, em local e condições indicados pela Central de Penas e Medidas Alternativas desta Comarca; e b) LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, pelo que deverá o réu manter-se recolhido em seu domicílio, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade substituída. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar DAVI MOREIRA JUNIOR, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, fixados no mínimo legal. Fixo a substituição da pena corporal por restritivas de direitos: a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade substituída, em local e condições indicados pela Central de Penas e Medidas Alternativas desta Comarca; e b) LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, pelo que deverá o réu manter-se recolhido em seu domicílio, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade substituída. Diante do regime intermediário fixado, a prisão cautelar se mostra incompatível. Com o encerramento da instrução e da aplicação do regime semiaberto, não se justifica a manutenção do cárcere provisório. Essa solução encontra guarida no princípio da proporcionalidade, haja vista que, em caso de manutenção da prisão preventiva, seria muito mais vantajoso para os condenados renunciar ao direito de recorrer, do que buscar a reforma da presente sentença. Em outras palavras, "verificado que foi imposto ao recorrente o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a segregação processual com o modo de execução que lhe foi determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso (RHC n. 48.138/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/11/2014)". Nesse sentido: "É incompatível a imposição/manutenção de prisão preventiva na sentença condenatória a réu condenado a cumprir a pena no regime inicial diverso do fechado, notadamente quando não há recurso da acusação quanto a este ponto. III - A tentativa de compatibilização da custódia cautelar com as regras do regime aberto ou semiaberto, neste caso, implica indevida execução provisória da pena. (Precedentes do STF). (STJ, 5ª Turma, RHC 52.407-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 10/12/2014)". Pelo exposto, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Fica autorizada a incineração da droga apreendida. Expeça-se guia de recolhimento provisória ou definitiva, conforme o caso. Transitada em julgado, resta o réu ciente de que deverá recolher pena de multa em dez dias, sob pena de inscrição na dívida ativa; oficie-se ao IIRGD e TRE/SP para os fins do art. 15, III, CF. Nos termos do art. 63 da Lei de Drogas. Declaro o perdimento de bens e dos valores eventualmente apreendidos em favor da União. Custas pelo acusado, observada a gratuidade de justiça.". Saem intimados os presentes, inclusive quanto ao prazo recursal."

Saem intimados os presentes, inclusive quanto ao prazo recursal. Ministério Público: Deseja recorrer desta sentença: () Sim (X) Não. Defesa: Deseja recorrer desta sentença: (X) Sim () Não. Réu: Deseja recorrer desta sentença: (X) Sim () Não.

Tendo sido a audiência realizada por videoconferência, ao final o presente termo foi exibido às partes, que concordaram com seus termos, ficando dispensada as assinaturas. Nada mais. Do que para constar, lavrei este termo, que lido vai devidamente assinado. Eu, _____, Bruno Luís Betti, escrevente técnico judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006